

1501644-18.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... que o acusado estivesse realizando o tráfico de entorpecentes no local dos fatos, sem que fossem avistadas condutas que indicassem a prática de comércio de drogas na ocasião. Ainda que houvesse, em tese, uma denúncia de tráfico no local dos fatos, caberia aos milicianos diligenciarem na região, a fim de apurarem se a delatio criminis teria algum fundamento. Caso, nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501644-18.2021.8.26.0599 - Controle nº 2021/001236

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2292738/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 21051068 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 121/21/592 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 2292738 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE DELPHINO

Réu Preso

Aos 22 de março de 2022, às 16:00h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: JOSE DELPHINO - PRESENTE (via videoconferência)

RAFA

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC MARCELO TEIXEIRA MENDES LINO DE OLIVEIRA - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC LEONARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha PC MARCELO TEIXEIRA MENDES LINO DE OLIVEIRA.

Dada a palavra à Dra. Promotora, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PC LEONARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, o que foi homologado pela MMª.

Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PC LEONARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu JOSE DELPHINO foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "JOSÉ DELPHINO, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 84/87. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 112), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 116/120), sendo a denúncia recebida (fls. 121/123). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, fotografia de fls. 10 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 75/77. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial civil Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que, após receberem informações dando conta de que um indivíduo de prenome "José", o qual estaria naquele exato momento sentado na Travessa Assis, defronte a viela que dá acesso à Favela do São Jorge, estaria guardando "kits" de entorpecentes destinados abastecer um ponto de trafico. Prontamente para lá se dirigiram e, chegando ao local indicado, abordaram cinco pessoas do sexo masculino, dentre elas o acusado JOSÉ DELPHINO, o qual era o único com esse prenome e, ao ser questionado, prontamente confessou ter no interior de seu imóvel entorpecentes destinados a venda,. Relatou que o réu franqueou a entrada no referido local, sendo um barraco de madeira, e indicou que os entorpecentes estariam sob o sofá, onde o declarante localizou um kit de maconha contendo 27 porções e outras 5 porções desta mesma droga. Afirmou que, ao ser cientificado que seria feita busca com cão de faro no quintal do barraco, onde existe uma área de mato e que termina na beira de um córrego, o acusado confessou que havia mais entorpecentes ali homiziados em uma sacola, sob um grande pedaço de telha zinco, próximo a um sofá velho. Aduziu que, realizada busca com cão de faro, o animal localizou uma sacola contendo outras 283 porções de maconha e 59 porções de cocaína, acondicionadas em vários "kits", no exato local apontado pelo acusado. Indagado, o acusado confessou que guardava as drogas para terceiros em troca de R\$ 80,00 semanais No mesmo sentido foram as palavras do policial civil Leonardo Cavalcanti de Oliveira, ouvido apenas na fase policial. Por fim, interrogado, o réu confessou os fatos a si atribuídos, alegando que de fato guardava todos os entorpecentes apreendidos, indicando aos policiais onde estavam elas escondidas. Confirmou o que foi falado pelo policial civil, no sentido que guardava a droga para uma pessoa em troca de R\$ 80,00 por semana. Disse, por fim, que assim agiu por dificuldades financeiras. Assim, ante a confissão do acusado que, foi corroborada pelo restante da prova produzida, tem-se que os fatos descritos na denuncia restaram cabalmente comprovados, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, haja vista que o acusado ostenta maus antecedentes (autos nº 0034958-03.2012 - fls. 89/90). Na segunda fase, verifica-se que o réu é reincidente específico (autos nº 0024434-44.2012 - fls. 88/90), bem como que confessou o delito. Na terceira fase, ante a reincidência específica, inaplicável o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial. JOSÉ DELPHINO, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como

incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 84/87. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 112), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 116/120), sendo a denúncia recebida (fls. 121/123). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, fotografia de fls. 10 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 75/77. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial civil Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que, após receberem informações dando conta de que um indivíduo de prenome "José", o qual estaria naquele exato momento sentado na Travessa Assis, defronte a viela que dá acesso à Favela do São Jorge, estaria guardando "kits" de entorpecentes destinados abastecer um ponto de trafico. Prontamente para lá se dirigiram e, chegando ao local indicado, abordaram cinco pessoas do sexo masculino, dentre elas o acusado JOSÉ DELPHINO, o qual era o único com esse prenome e, ao ser questionado, prontamente confessou ter no interior de seu imóvel entorpecentes destinados a venda,. Relatou que o réu franqueou a entrada no referido local, sendo um barraco de madeira, e indicou que os entorpecentes estariam sob o sofá, onde o declarante localizou um kit de maconha contendo 27 porções e outras 5 porções desta mesma droga. Afirmou que, ao ser cientificado que seria feita busca com cão de faro no quintal do barraco, onde existe uma área de mato e que termina na beira de um córrego, o acusado confessou que havia mais entorpecentes ali homiziados em uma sacola, sob um grande pedaço de telha zinco, próximo a um sofá velho. Aduziu que, realizada busca com cão de faro, o animal localizou uma sacola contendo outras 283 porções de maconha e 59 porções de cocaína, acondicionadas em vários "kits", no exato local apontado pelo acusado. Indagado, o acusado confessou que guardava as drogas para terceiros em troca de R\$ 80,00 semanais No mesmo sentido foram as palavras do policial civil Leonardo Cavalcanti de Oliveira, ouvido apenas na fase policial. Por fim, interrogado, o réu confessou os fatos a si atribuídos, alegando que de fato guardava todos os entorpecentes apreendidos, indicando aos policiais onde estavam elas escondidas. Confirmou o que foi falado pelo policial civil, no sentido que guardava a droga para uma pessoa em troca de R\$ 80,00 por semana. Disse, por fim, que assim agiu por dificuldades financeiras. Assim, ante a confissão do acusado que, foi corroborada pelo restante da prova produzida, tem-se que os fatos descritos na denuncia restaram cabalmente comprovados, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, haja vista que o acusado ostenta maus antecedentes (autos nº 0034958-03.2012 - fls. 89/90). Na segunda fase, verifica-se que o réu é reincidente específico (autos nº 0024434-44.2012 - fls. 88/90), bem como que confessou o delito. Na terceira fase, ante a reincidência específica, inaplicável o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado Silvio foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. O acusado Michel, corréu na presente ação penal, possui Advogado constituído nos autos. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende, em sede PRELIMINAR, que as provas obtidas nos autos, em especial as substâncias entorpecentes encontradas pelos Policiais, são ilícitas, eis que constituídas a partir da invasão indevida do domicílio do acusado. Isso porque, de acordo com os elementos colhidos durante o processo, percebe-se que não estavam presentes nenhuma das exceções para a mitigação da garantia fundamental prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República. Como se observa do interrogatório do acusado, tem-se que o ingresso dos agentes na residência em questão ocorreu sem autorização dos moradores e apenas em função de suspeitas de que o acusado estivesse realizando o tráfico de entorpecentes no local dos fatos,

sem que fossem avistadas condutas que indicassem a prática de comércio de drogas na ocasião. Ainda que houvesse, em tese, uma denúncia de tráfico no local dos fatos, caberia aos milicianos diligenciarem na região, a fim de apurarem se a delatio criminis teria algum fundamento. Caso, nesta averiguação, constatassem, efetivamente, um flagrante, poderiam, então, realizar a prisão do autor (dever legal, segundo os arts. 301 e 302 do CPP); caso, no entanto, houvesse apenas indícios de prática criminosa, deveriam, então, buscar autorização judicial para realização de campanhas (art. 53, II, da Lei nº 11.343/06), ou para a expedição do mandado de busca domiciliar para a colheita de elementos probatórios necessários à comprovação da infração, nos exatos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal. Ademais, não se pode respaldar tal procedimento sob a assertiva de que o tráfico seria crime permanente. Com efeito, independentemente da natureza do delito (instantâneo ou permanente), a mitigação da garantia em voga não prescinde da constatação, ex ante, da situação flagrancial pelo agente que fará a incursão na residência, o que não ocorreu no caso. E, ainda que superadas tais considerações, entendendo-se que o flagrante posterior ao ingresso na residência convalide, em tese, a diligência policial e a própria prova colhida, cabe, então, observar que não é qualquer ato flagrancial que autoriza a invasão domiciliar, em respeito ao princípio constitucional da proporcionalidade. Isso porque a exceção aberta aos casos de flagrante delito evidentemente visa a permitir a invasão de residências em que um crime “natural” está sendo cometido; ouvem-se os gritos da vítima, os tiros do ladrão, as surras do pai na criança. Sempre hipóteses em que a vida humana, ou mesmo o patrimônio, correm perigo concreto e imediato, nada justificando que a hipótese de que haja entorpecentes escondidos, para futura comercialização, autorizem a invasão policial sem mandado judicial. Dessa forma, tendo sido a apreensão dos entorpecentes diretamente ligados à invasão de domicílio, pois eles só foram (em tese) encontrados após a detenção da acusada e no interior do imóvel, de rigor reconhecer-se a nulidade do laudo de constatação e do laudo do exame químico-toxicológico, por constituírem provas ilícitas por derivação, nos exatos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. Consequentemente, verifica-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público é ausente de justa causa (art. 395, III do CPP) por falta de comprovação da materialidade delitiva, razão pela qual se requer seja declarada a nulidade do processo ab initio, em relação à imputação da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Todavia, se superada a preliminar, QUANTO AO MÉRITO, as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Marcelo, Policial Civil, declarou que recebeu uma informação de que um indivíduo chamado “José” estaria na entrada da Favela São Jorge e teria recebido entorpecentes para abastecer pontos de vendas de drogas. A denúncia também passava as vestimentas do indivíduo e o local onde ele morava. Foram ao local indicado e abordaram 06 indivíduos, mas os demais foram liberados. Ao ser indagado, o réu confessou informalmente que guardava drogas em sua residência e indicou o local onde elas estavam (embaixo do sofá da residência). Encontraram os entorpecentes neste local. Porém, nos fundos do barraco haveria uma área de mata e, quando foi informado sobre o uso do cão farejador, o réu disse que guardava mais drogas embaixo de uma telha na área de mata. O cão, de fato, localizou as drogas onde ele indicou. O acusado disse que guardava as drogas porque passava necessidades e recebia dinheiro por isso. O réu, em interrogatório, declarou que os fatos são verdadeiros. Estava sem trabalho, seu filho tinha acabado de nascer e sua mãe é deficiente visual. Por conta das necessidades financeiras que passavam, aceitou pegar as drogas e guardar em sua residência, em troca de receber R\$ 80,00 por semana. Com isso, comprava leite para seu filho e algumas fraldas geriátricas para sua mãe. Excelência, em que pese o acusado ter reconhecido a prática dos fatos, sua confissão, como qualquer outra prova, possui valor relativo e deve ser corroborada pelo restante dos elementos dos autos, o que não ocorreu neste caso. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Policiais

responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se, pelo próprio depoimento dos Policiais, que, a despeito da "denúncia anônima" recebida (sequer comprovadas nos autos, diga-se de passagem), nenhum ato de comércio foi avistado antes da abordagem e não foram apresentados outros indivíduos na Delegacia de Polícia como testemunhas presenciais dos fatos e/ou como possíveis usuários das substâncias entorpecentes (embora os próprios agentes mencionem que outras pessoas foram abordadas). Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Todavia, caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminoso), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional

porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFE, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao eu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição (“O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos”, in Direitos Humanos – Visões Contemporâneas, edição de Associação Juizes para a Democracia, 2001). Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (ainda que extrajudicial), compensando-a com eventual agravante da reincidência, diante do caráter subjetivo e preponderante de ambas as circunstâncias; (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iii) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, com eventuais substituições de pena que se mostrarem cabíveis, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ e, ainda, em razão do disposto no art. 387, § 2º, do CPP; (iv) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva”.

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

JOSÉ DELPHINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 14h20, na Rua Pereiras, nº 379, bairro São Jorge, nesta cidade e comarca de Piracicaba, guardava e tinha em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 59 (cinquenta e nove) “eppendorfs” de cocaína em pó, pesando cerca de 17,2g (dezessete gramas e dois decigramas), e 315 (trezentas e quinze) porções de maconha, pesando aproximadamente 402,3g (quatrocentos e dois

gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que policiais civis receberam informações dando conta de que um indivíduo de prenome "José" estaria guardando "kits" de entorpecentes destinados ao tráfico, bem como que ele estaria sentado na Travessa Assis, defronte à viela que dá acesso à "Favela São Jorge". Com o escopo de apurar a veracidade da denúncia, os investigadores rapidamente se deslocaram até o local informado e procederam a abordagem do acusado. Indagado, JOSÉ confessou aos agentes públicos que guardava em sua residência entorpecentes para terceiros, recebendo pelo "serviço", a quantia de R\$80,00 semanais. Ademais, o acusado franqueou a entrada dos policiais em sua moradia, um barraco de madeira, e indicou o local onde as drogas estavam homiziadas. Os policiais civis, então, realizaram diligências nos locais indicados por JOSÉ e, com a ajuda de um cão farejador, apreenderam os entorpecentes retro descritos. Na delegacia, o acusado manteve a confissão.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 112) e apresentou defesa preliminar (fls. 116/120), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia (fls. 121/123).

Designada audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia e interrogado o réu.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. Não há qualquer impedimento legal para que as investigações criminais tenham origem em denúncia anônima.

É de se convir que denunciar a prática de crimes, fora do manto do anonimato, é algo que amedronta o homem médio, que, não compactuando com a impunidade, vale-se desse meio para buscar segurança e repressão aos delitos de que tem ciência.

As delações anônimas, aliás, têm contribuído de forma significativa na elucidação de delitos, tanto que o Estado mantém serviço para acolhê-las, o chamado 'disque-denúncia'. Logo, seria um contrassenso que policiais recebessem informação sobre a prática de crime e, em razão do anonimato sob o qual é feita, quedassem-se inertes. É certo que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, a denúncia anônima não legitima o ingresso de policiais no domicílio.

Nesse contexto, o E. Supremo Tribunal Federal, a fim de coibir excessos e arbitrariedade, assentou entendimento segundo o qual o ingresso em residência, sem autorização do morador e sem ordem judicial, para ser lícito, demanda quadro de fundada suspeita de situação de flagrante delito. Logo, os policiais somente podem adentrar em residência se tiverem dados concretos indicativos da ocorrência de um crime, impondo-se controle jurisdicional posterior da diligência para se definir se a ação policial era justificada ou não.

Confira-se, sobre o tema, o julgado em que assentado o entendimento do Pretório Excelso: "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.

Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo

17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (STF, RE nº 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes).

Esse mesmo entendimento pode ser aplicado à busca pessoal, face ao que dispõe o art. 240, § 2º, do CPP.

No caso em tela, como se verá, os policiais esclareceram que, após receberem denúncia anônima dando conta de que indivíduo com o prenome do réu teria recebido entorpecentes e estava na entrada da favela São Jorge. Então, para lá se dirigiram e abordaram o acusado, que confirmou ter entorpecentes em sua residência, razão pela qual seguiram até local, onde apreenderam as drogas.

A abordagem do acusado e o consequente ingresso dos policiais no imóvel não constituiu ação arbitrária. Havia justa causa para a ação, sendo lícitas as provas daí decorrentes.

Não é demais observar que, interrogado em juízo, o réu atestou que os fatos se passaram tal como relatados pelo policial Marcelo, respaldando, assim, a ação policial.

2. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, pela fotografia de fls. 10 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 13/18, que trouxe resultado positivo para maconha e cocaína.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu confessou a prática do crime. Disse que, na data dos fatos, estava na via pública quando foi abordado por policiais que lhe perguntaram se estava na posse de entorpecentes. Na ocasião, respondeu aos agentes públicos que não trazia nada consigo, porém, na sua casa, havia maconha e cocaína. Afirmou que indicou para eles o esconderijo das drogas, estando um kit com porções de maconha sob o sofá e o restante dos kits de maconha e de cocaína em uma área de mata, nos fundos da casa. Asseverou que, desde o início da ocorrência, colaborou com os policiais. Alegou que estava guardando as drogas para uma pessoa, cujo nome não desejava informar, recebendo R\$80,00 por semana. Disse que estava arrependido (fls. 05/06).

Em juízo, ratificou sua confissão. Disse que tinha acabado a obra na qual estava trabalhando e estava sem serviço. Alegou que seu filho tinha acabado de nascer e sua mãe é deficiente visual. Declarou que acabou pegando pequena quantidade de entorpecente para guardar em sua casa e recebia R\$ 80,00 por semana. Assim, conseguia comprar um pouco de leite para seu filho e, mesmo assim, pedia ajuda para outras pessoas.

A confissão foi amparada pelas provas produzidas.

O policial civil Marcelo relatou que, no dia dos fatos, receberam informação dando conta de que um indivíduo de prenome José estaria, naquele momento, na entrada da favela São Jorge e teria recebido entorpecente, que guardava no barraco para abastecer o ponto de venda do local. Atestou que só tinha o prenome do indivíduo e a localização exata do barraco. Disse que seguiu até o local, na entrada da comunidade, encontrou seis indivíduos, que foram todos abordados e identificados. Asseverou que nada de ilícito portavam e só um tinha o prenome José. Então, os

demais foram liberados e José foi questionado se tinha algo ilícito no barraco, sendo informado da denúncia e de que tinham a exata descrição do barraco. Então, ele falou que tinha droga ali e os acompanhou até o barraco, onde informou que a droga estava embaixo do sofá. Afirmou que encontrou porções de maconha no local informado, mas questionou o réu se havia mais alguma coisa, informando-o que estavam com o cão de faro na viatura, até porque havia uma extensa área de mata nos fundos do barraco, que terminava num córrego. Disse que o réu afirmou que tinha mais drogas embaixo de pedaço de telha. Então, soltaram o cão de faro, que foi direto ao ponto que o réu indicou, onde encontraram uma sacola com kits de maconha e cocaína. Relatou que o réu falou que passava por necessidades e ganhava R\$ 80,00 por semana para guardar a droga, mas não queria informar quem era o dono do entorpecente por medo de represálias. Atestou que, de fato, o barraco era bem precário.

No mesmo sentido o depoimento do policial civil Leonardo, ouvido a fls. 04. É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais civis não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E “como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Enfim, o fato de os policiais civis terem recebido denúncias da prática de tráfico no local e, logo após, terem localizado as porções de maconha e cocaína nos esconderijos indicados pelo próprio acusado, que confessou que estava guardando as drogas em troca de dinheiro, conduzem à certeza quanto à autoria e a traficância. A quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos e a forma como estavam acondicionados, aliados à existência de denúncia prévia dando conta da traficância e à confissão do acusado, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, cabendo anotar que, para sua configuração, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente guarde ou tenha em depósito a substância entorpecente.

O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de conteúdo múltiplo. Descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas.

Manter em depósito e transportar ou guardar entorpecentes para fins de tráfico, isto é, para venda, distribuição ou entrega ao consumo de terceiros – configura e se subsume perfeitamente ao tipo penal em comento, sendo irrelevante o fato de que o réu eventualmente não promovesse atos de venda.

3. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que o réu é reincidente, inclusive, específico (fls. 88/91). Essa circunstância, porém, só pode ser considerada na segunda fase de fixação da pena, evitando-se bis in idem. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, observo que o réu é duplamente reincidente (processo n. 0024434-2012 da 3ª Vara Criminal local e 0034958-03.2012 da 1ª Vara Criminal local – certidão fls. 88/91). De outra banda, confessou a prática do delito. Logo, sopesando as circunstâncias agravante e atenuante, aumento a pena

fixada em um sexto, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Inexistem causas de aumento e, por ser reincidente, não faz jus o réu à redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, em decorrência da reincidência específica e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII).

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, valendo observar que o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a perseguição criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

4. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu JOSÉ DELPHINO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU e DEFENSOR foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data.

2) Cumpra-se a Res. 09/85 do TJSP, oficiando-se ao IIRGD e TRE.

3) Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

4) Sai o réu intimado na audiência realizada nesta data, 22/03/2022, para que efetue o pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias, no valor de R\$22.404,56,

equivalente a 700,80 UFESPs nos termos do Art. 50 do Código Penal e Art.479, caput, NSCGJ, sob pena de execução do débito a ser ajuizada pelo Ministério Público.

5) O réu foi assistido por Defensor Público, logo, está isento das custas processuais.

6) Oportunamente, archive-se.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MM^a. Juíza de Direito da 4^a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUIZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]